

1500445-04.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia-SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500445-04.2021.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-04.2021.8.26.0035

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288538/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 20969698 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 1805/21/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2288538 - DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA, 1805/21/112 -

DEL.POL.AGUAS DE LINDOIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SILVERIO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Daniel Silverio Pereira, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que ("no dia 22 de outubro 2021, por volta da 1h50min, na Rua João de Souza Carvalho, nº 135, Águas de Lindoia, DANIEL SILVÉRIO PEREIRA transportava e trazia consigo cocaína, sob a forma de pó (6,3 g divididas em 4 porções, acondicionadas em microtubos individuais) e também de pedras de crack (4,9g, divididas em 27 porções individualmente embaladas em plástico), para fins de

consumo de terceiros, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O local dos fatos é conhecido ponto de vendas de droga. Lá, agentes da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, localizaram o denunciado DANIEL em atitude suspeita, ao empreender imediata tentativa de fuga à pé ao avistar a aproximação da viatura policial, dispensando, no trajeto, uma sacolinha que trazia consigo. DANIEL foi capturado e trazia em seus bolsos R\$ 319,00. Já a sacola por ele dispensada no trajeto de fuga foi recuperada, constatando que em seu interior havia a cocaína, sob a forma de pedras de crack e de pó") (fls. 61/63).

A denúncia foi recebida em 19/04/2022.

Promovida a notificação (fls. 81), Daniel Silverio Pereira apresentou defesa prévia (fls. 67/68).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo laudo de exame pericial (Entorpecentes - fls. 106/114), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Renan Francisco Rangel (policial militar) relatou que estavam em patrulhamento e no momento que adentraram uma rua conhecida nos meios policiais como um ponto de venda de drogas vieram o acusado saindo correndo pelo escadão que dá acesso à via de baixo; que correu atrás dele a pé e o motorista deu a volta pela rua de baixo; que a viatura o cercou; que fizeram uma revista pessoal, localizaram dinheiro; que quando corria atrás dele foi nítido que ele dispunha de uma sacola branca no meio desse escadão, então voltaram e constataram quantidade de droga em uma sacola plástica; que, depois, conduziram-no à delegacia; que é comum o tráfico no escadão, pois atrapalha a perseguição pela viatura; que ele estava sozinho; que ele não deu explicação, ficou em silêncio; que a ação não foi registrada em áudio ou vídeo nem houve testemunhas; que não localizaram usuários compradores da droga.

Já a testemunha Daniel Holanda de Castro relatou que no dia estavam patrulhando o local, já conhecido pela venda de entorpecentes; que ao chegar lá visualizaram o indivíduo e ele saiu correndo; que manobrou a viatura e conseguiu abordá-lo; que em revista localizaram dinheiro; que seu parceiro viu jogando uma sacola plástica e

então constatararam que nela havia drogas; que ele não deu explicação e estava sozinho; que a ação não foi registrada em áudio ou vídeo nem houve testemunhas; que não localizaram usuários compradores da droga.

O acusado, por fim, relatou que estava no local fumando, usando, quando apareceu a viatura; que correu com medo de apanhar, porque havia um comentário de que os policiais espancavam usuário e traficante; que a viatura o parou e acharam dinheiro e depois eles acharam a droga mais para cima, para o lado do escadão; que o que tinha para usar eram duas pedras; que já tinha usado quando foi abordado, aí levantou e viu a viatura; que desceu o escadão correndo; que não viu nada no escadão; que os policiais não o agrediram; que o que o pessoal comenta é do Cassiano, da Civil, que eles batiam, mas não conhecia, então correu; que eles devem estar inventando as drogas pelo local onde estava; que acha que eles encontraram essa droga, mas não viu no local; que é usuário desde os doze anos.

Diante das provas produzidas, quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obter o que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

No caso ora em apreço, verifica-se que o depoimento dos policiais é uníssono quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão, no sentido de que o acusado fugiu da viatura ante a aproximação desta e inclusive dispensou uma sacola durante a fuga, o que ensejou a sua abordagem e revista, com a localização de drogas na sacola dispensada e dinheiro consigo. Quanto à hipótese alternativa ventilada, mostra-se de reduzida verossimilhança. Não é verossímil que a droga tenha sido localizada a esmo e aleatoriamente pelos policiais em plena via pública. Não foi apurada razão para que os policiais militares forjassem a droga em desfavor do acusado, inventando que viram a droga ser dispensada.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos

quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). O que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

Quanto à tese de desclassificação, a conduta percebida pelos policiais não é compatível com o uso de drogas, notadamente porque a variedade de espécies de droga não se coadunam com tal hipótese alternativa defensiva.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a folha de antecedentes juntada aos autos não contém nenhuma condenação penal definitiva apta a ser desvalorada nesta fase (cf. Súmula 444/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria, para fixação do patamar da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fim de evitar *bis in idem* indireto, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM, Plenário, j. 3.4.2014, Tema 712 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, j. 09/06/2021).

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes, razão pela qual a pena provisória deve ser mantida no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há majorantes.

Quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa.

No caso, a folha de antecedentes comprova o preenchimento dos dois primeiros requisitos. De outro lado, o acervo probatório, cujo objeto se concentra, em suma, em uma abordagem policial ocasional e eventual, não demonstra nem a dedicação do agente a atividades criminosas, nem a sua integração a organização criminosa. Todas as provas coletadas o foram a partir de abordagem policial ocasional e pontual, sem indícios de reiteração delitiva. Logo, é imperativo o reconhecimento da incidência da aludida minorante. As circunstâncias preponderantes já foram examinadas na terceira fase, de modo que se impõe a fixação da minorante no patamar máximo. O fato superveniente, apurado nos autos n. 1500488-38.2021.8.26.0035 não pode servir como antecedente ou fato configurador de dedicação a atividades criminosas na data anterior do fato apurado nestes autos. Assim, naquele processo, viável o afastamento da minorante, mas não nesse, em que a conduta anterior do acusado está pouco esclarecida.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame. Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais uma espécie de substância ilícita, de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Ademais, quanto à cocaína/crack, trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga apreendida, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita.

Por tais razões, fixa-se a minorante no patamar intermediário de 1/2 (um meio) e fixa-se pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto, com base no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

Não houve decretação de prisão cautelar durante o curso da persecução penal, de modo que não há detração a ser promovida neste ato (CPP, art. 387, § 2º).

Ante o preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, as quais ficam desde já individualizadas como (1) prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária que será informada posteriormente, em audiência admonitória, para destinação a entidade pública ou privada com destinação social, em atenção à Resolução n. 154/12-CNJ; e (2) prestação de serviços à comunidade, por tempo igual ao da condenação, em entidade a ser designada na fase de execução penal.

Ante a substituição por pena restritiva de direitos, fica prejudicado o exame da

suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III).

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado DANIEL SILVÉRIO PEREIRA ao cumprimento de de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos na forma supra, mais 250 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto à prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, não estão presentes os requisitos legais.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA